

1500172-66.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... para garotas, configurando do mesmo modo o tráfico nessa hipótese.

Por conseguinte, provada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a procedência do pedido condenatório é de rigor.

Delineada a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, resta fixar a reprimenda devida.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500172-66.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-66.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131798/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 24978618 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2131798 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WERNER FAGUNDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra WERNER FAGUNDES, denunciado como incurso no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 15 de maio de 2022, por volta de 01h20min, na Rua Natal Penha, nº 41, Residencial San Miguel, nesta cidade e comarca de Adamantina, WERNER FAGUNDES, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, o total de 7,86 g (sete gramas e oitenta e seis centigramas) de tetanfetamina, droga popularmente conhecida como "ecstasy", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, fls. 01, com conversão em preventiva, fls. 54/58.

Decisão liminar em sede do Habeas Corpus, fls. 71/75, concedendo a liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares.

Decisão determinando a expedição do alvará de soltura clausulado, fls. 100, prestando as informações requisitadas, fls. 102/106.

Alvará de Soltura expedido, fls. 110/112, e devidamente cumprido, fls. 123/126.

A denúncia foi oferecida em 12 de julho de 2022, fls. 172/173.

Determinada a notificação do denunciado para apresentação de defesa prévia, conforme decisão de fls. 174.

O acusado foi notificado, fls. 190, e apresentou defesa prévia, fls. 191/195.

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento da ação penal, fls. 199/201.

Em decisão de fls. 205/206 foi afastada a argumentação da defesa quanto à nulidade da apreensão e a alegação de falta de justa causa, não houve acolhimento do pedido de absolvição sumária, sendo recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução, fls. 249/250, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, três testemunhas da defesa, bem como interrogado o réu.

Encerrada a instrução foi concedido prazo às partes para apresentarem memoriais escritos.

O Ministério Público, em síntese, considerou provada a autoria e materialidade delitiva do crime imputado ao réu, alegando que todas as provas produzidas nos autos são suficientes para o decreto condenatório, pugnando pela procedência da ação, fls. 255/274.

Por seu turno, a Defesa, fls. 278/285, preliminarmente reiterou a arguição de nulidade da busca e apreensão, alegando ter sido obtida de forma ilícita. No mérito, resumidamente, ressaltou que não restou provada a ocorrência do tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória, pugnando pela absolvição do acusado ou a desclassificação do crime, ora imputado, para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

Por primeiro, destaco que a arguição de nulidade da busca e apreensão por meio da revista pessoal não merece acolhimento, conforme já decidido às fls. 205/206.

Aliás, não há falar em ilicitude de prova, eis que evidente a fundada suspeita de flagrante delito a permitir a abordagem e a revista pessoal. Havia denuncia com elementos específicos. Feita a campana, foi verificada pessoa com as mesmas características da denuncia, a caminho da festa que reuniria milhares de pessoas da região na pequena cidade de Adamantina, ambiente de fato propício a venda de "drogas sintéticas".

Logo a omissão dos policiais em realizar abordagem e revista, registre-se, em via publica, não só seria conduta ilegítima, como criminosa.

Além disso, a busca pessoal independe de mandado judicial em caso de existir evidente suspeita de cometimento de crime, nos termos dos artigos 240, §2º, e 244, do Código de Processo Penal, exatamente como no caso em questão.

Nesse sentido: "Ilegalidade da prova obtida - Alegada abordagem e busca pessoal imotivada - Fundada suspeita demonstrada - Abordagem pessoal, em conformidade com os artigos 240 e 244 do CPP - Preliminar rejeitada. Tráfico de Drogas -

Insuficiência probatória - Absolvição - - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida. Corrupção ativa - Insuficiência probatória - Existência de provas da autoria e materialidade do delito - Crime de natureza formal que se aperfeiçoa com a oferta ou promessa de vantagem indevida - Condenação mantida. Pena-base - Reconhecimento como favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - Agente portador de maus antecedentes encontrado com grande quantidade e variedade de drogas, inclusive aquelas de alto poder viciante - Pleito desprovido. Segunda fase da dosimetria - Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a circunstância agravante da reincidência, em relação ao crime de tráfico - Apelante que admitiu que atuou

como "mula" - Recurso parcialmente provido para reduzir as penas. Segunda fase da dosimetria - Circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal - Reconhecimento, tendo em vista a situação de vulnerabilidade do acusado - Impossibilidade - Pleito não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1529180-50.2021.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022).

Desta forma, ao invés de críticas, é sim razão de aplausos a seriedade da conduta dos policiais civis Nicolý Rossi Jaccoud e Alex José Marin Leite, com a denúncia que receberam, assim como exemplar a conduta durante a ação, que resultou na apreensão de significativa quantidade de droga, que deixaram de atingir no mínimo uma dezena de pessoas.

Pois bem.

Das declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e do interrogatório réu, extrai-se o que segue:

A testemunha Nicolý Rossi Jaccoud, Policial Civil, declarou que estavam trabalhando em uma operação de uma festa que iria acontecer no clube "ATC". Que receberam uma denúncia anônima de que Werner iria trazer ecstasy para a festa. Que souberam que ele estava em uma chácara, então identificaram o local e com uma viatura descaracterizada ficaram nas redondezas observando as movimentações. Que em um momento várias pessoas saíram da chácara e ficaram na rua, momento em que uma "Van" chegou e então essas pessoas entraram. Que realizaram a abordagem, momento em que viram o réu dispensar dois saquinhos de drogas, sendo que um ele pisou em cima e o outro ficou entre sua mão e sua carteira. Que não conheciam o réu. Que souberam identificar o réu por meio de redes sociais. Que foram feitas revistas pessoais em todas as pessoas que estavam aguardando a "Van". Que durante a abordagem o réu demonstrou um comportamento inquieto. Que tinha por volta de doze pessoas para entrar na van. Que a distância da chácara para o local da festa é aproximadamente de três quilômetros.

A testemunha Ana Carolina Whitaker declarou que foi convidada por uns amigos para ir a uma chácara antes do início da festa "Black". Que não foi durante a tarde na chácara, apenas foi à noite para levar as meninas que estavam juntas e ir todos para a "Black". Que estavam escutando música normalmente. Que o réu disse que havia pedido uma Van para irem até a festa, pois as meninas estavam de salto. Que a Van chegou juntamente com a polícia civil. Que no início a abordagem foi bem truculenta e desrespeitosa. Que todo mundo ficou com a mão na parede para serem revistados. Que não viu ninguém com entorpecente. Que o réu estava do seu lado. Que a policial pediu para trocar de lado para ficar as meninas de um lado e os meninos do outro. Que o outro policial estava conversando com o réu. Que na hora que estava colocando o seu sapato, o réu derrubou um saquinho com "balas" (ecstasy) no chão e no desespero o réu chutou em sua direção. Que a policial disse que o réu estava e passando a droga a ela, momento em que afirmou que não estava até porque nem o conhecia. Que a policial a ameaçou perguntando se havia visto aquela cena, dizendo que se a droga não era do réu seria sua. Que a policial lhe questionou se poderia servir como testemunha, então aceitou e foi para a Delegacia.

A testemunha Devair Flores de Sousa declarou que conhece Werner desde o ano de 2007. Que ficou sabendo dos fatos que ocorreram na época, até ficou surpreso. Que é policial militar. Que o pai do réu tem uma loja de carros e um restaurante perto do Pelotão. Que conheceu o réu por causa do pai dele. Que o réu sempre teve uma conduta fina e nunca viu nada que o desabone.

A testemunha Flávio Aparecido Terçarioli da Silva declarou que conhece o réu desde quando ele nasceu. Que o réu é uma pessoa trabalhadora, honesta, sempre estava junto com seu pai e família. Que Werner (réu) sempre foi uma pessoa de princípios.

A testemunha Agemiro Salmeron declarou que conhece o réu Werner desde o dia que ele nasceu, pois morava do lado de sua casa. Que ele era amigo de suas filhas. Que o réu é um menino muito educado e sem vícios. Que o réu trabalha com o pai que possuem dois hotéis e também mexe com vendas de carros. Que todos ficaram surpresos

com os fatos, pois ninguém esperava isso. Que o réu é uma pessoa de boa índole e nunca se envolveu com nada de errado.

O réu Werner Fagundes declarou que sabe do que esta sendo acusado. Que na data do fato alugaram uma chácara na cidade de Adamantina para passarem o final de semana com o intuito de irem para a festa "Black". Que podiam chegar sábado à noite e ficarem até domingo à noite. Que devido o local ser grande deixaram o portão aberto. Que por volta meia-noite todos começaram a sair para irem à festa. Que o local da festa era um pouco longe então decidiram alugar uma Van. Que quando a Van parou dois carros de polícia descaracterizados chegaram, parando na frente e atrás da Van. Que os policiais começaram a abordagem utilizando armas, mandando todos colocar as mãos na cabeça. Que no início pensou que era um assalto, mas depois percebeu que se tratava de policiais, pois estavam com faroletes. Que estava com dois pacotes de "bala" (ecstasy) em baixo do seu tênis. Que no momento em eu acabou a revista, na hora que ia sair a policial viu a droga. Que no primeiro momento negou que a droga era sua, pois pensou que iria ser liberado. Que ia utilizar a droga na festa "Black" e continuaria a festa na chácara. Que a droga era para seu uso. Que os dois pacotes era devido já ter perdido droga em revistas, então possuindo dois pacotes as colocaria em lugares diferentes. Que utiliza em média de dez a quinze "balas" por festa. Que trabalha como gerente, é solteiro e não possui filhos. Que não houve apreensão de dinheiro ou máquina de cartão em sua posse. Trata-se o presente caso de acusação de cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, com aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

É certo que o mero "trazer consigo" já é mais do que suficiente para a configuração do tráfico, a teor do artigo 33 da Lei de Drogas: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O somatório dos elementos de prova colhidos nos autos traz a certeza de que o réu "trazia consigo" substância entorpecente (ecstasy), para entrega a consumo de terceiros, praticando, assim, em essência, o crime de tráfico.

É incontroverso nos autos que o réu foi abordado em uma chácara com destino a uma festa de música eletrônica, conhecida com "Rave", em posse de 17 (dezessete) comprimidos de ecstasy, somando 7,86 g (sete gramas e oitenta e seis centigramas) de "Tenanfetamina - MDA", droga sintética psicoativa.

Conquanto o réu, em sua defesa, assegurar que droga era para uso próprio, tal versão não pode ser acolhida, já que as provas indicam a traficância, especialmente em razão da natureza e quantidade da droga (17 comprimidos de ecstasy).

Incabível imaginar que o réu consumiria sozinho toda a quantidade de droga com ele apreendida, como alegou em interrogatório, e que costumava ingerir até quinze (15) comprimidos numa noite. O consumo de tal quantidade é improvável até mesmo para viciados e o consumo desse volume em curto período poderia levar o usuário a perturbação e sequelas psicomotoras graves.

É crível que o réu realmente era usuário, mas tal circunstância, por si só, não afasta o fato de que ele, na ocasião, estava realizando o tráfico de drogas, já que a destinação da droga apreendida era o comércio ilícito.

Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de pedido de perícia na defesa preliminar e durante a instrução. Ausência de elementos que justifiquem a realização de exame.

Mérito. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade de droga, forma de acondicionamento, circunstâncias do crime e da prisão que revelam a incompatibilidade de transporte para mero uso e evidenciam a venda e a destinação à mercancia. Penas e regime bem aplicados NEGADO PROVIMENTO AO APELO". (TJSP; Apelação 0001323-43.2016.8.26.0628; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).

Anote-se, aliás, que embora apontado peso de pouco mais de 7 gramas, foram

recuperados 17 comprimidos intactos, posto que o réu, quando da abordagem, para "disfarçar" o montante de droga, teria deteriorado parte dos "comprimidos", como consignado as fls.02: "...Em revista a WERNER que estava entre aquelas pessoas, em suas vestes nada encontraram, contudo o mesmo retirou dois saquinhos plásticos da carteira e dispensou no chão, pisando em um deles. Rapidamente, resgataram do chão os saquinhos, e constaram estarem acondicionando comprimidos de ecstasy, (17 comprimidos) contudo alguns acabaram sendo "amassados" em uma nítida intenção de dispensar seu conteúdo."

A propósito, as conversas extraídas do celular do réu comprovam de forma clara e objetiva a existência do seu envolvimento com o tráfico de drogas, é o que se verifica do Relatório de Investigação (fls. 140/163), vejamos trechos das transcrições:

(fls. 143)

- Dia 14 de maio, imagem 12:
- Werner - 15:20 horas: Vc vendeu 3 bala pro Luca; Por 100 em; kkk; Vagabundo
- Renan - 15:20 horas: Sim; Mais não são essas; Aí
- Werner - 15:20 horas: Quais são
- Renan - 15:20 horas: Vc levou ele?

Nota da investigação: Werner informou para o contato Renan que sabe que ele (Renan) vendeu "bala" para "Luca" por 100, que confirma (sim), em seguida afirmando que não são essas aí (que estariam com Werner).

(fls. 144/145)

- Dia 14 de maio, imagem 13:
- Renan - 15:21 horas: Nem abre a boca; Essa boca aberta sua aí
- Werner - 15:21 horas: Eu sei caraí; RLX
- Renan - 15:21 horas: Ok
- Werner - 15:21 horas: Mais lá; Vai estar o Nandex; Se ele colar perg; Cara vai fala; Se for esperto
- Renan - 15:21 horas: Nao tem nada ave uma coisa com. A outras
- Werner - 15:21 horas: Certo Favato; Hrs vc vem?
- Renan - 15:21 horas: Depois que eu compro quem põem preço sou eu

- Dia 14 de maio, imagem 14:

- Werner - 15:22 horas: Problema seu kkk (comentando a mensagem anterior de Renan: "Depois que eu compro quem põem preço sou eu"); E dos enganados
- Renan - 15:22 horas: Lógico (comentado a mensagem anterior de Werner: "E dos enganados"); Quem quiz foi ele

- Dia 14 de maio, imagem 15:

- Werner - 16:49 horas: Ow vou dar uma bala ruim; Dessa da Amanda; Aí vc da pro Lucas

- Werner - 16:50 horas: Trocar a boa pela ruim; Vc soca nele; Blz
- Renan - 16:50 horas: Ow; O que ?
- Werner - 16:50 horas: Ele não sabe caraí; Aquela azul ruim;

Vou te dar as 10; Aí 9 das normal e 1 da Amanda; E 1 boa eu seguro cmg

Nota: Após preocupação por parte de Renan, para que não saibam sobre preço da venda de "bala", informa que depois que adquire, quem coloca o preço para venda é ele, alegando que, quem compra é que tem o interesse pelo preço. Em seguida Werner tenta negociar tipos de "bala", em boas e ruins, com Renan para que sejam repassadas para um comprador, alegando que este não saberia diferenciar.

(fls. 146/147)

- Dia 14 de maio, imagem 16:
- Renan - 16:50 horas: Não não; Não dá mano; As 10 Boas já estão vendidas;
- Renan - 16:51 horas: Nem mexe; As dele ta aqui já; As ruim
- Werner - 16:51 horas: Troca aí; Uma da Amanda cmg; Nessa boa
- Renan - 16:51 horas: Já vendi tudo dessas boa
- Werner - 16:51 horas: Vendeu mais que 1; Pra alguém
- Renan - 16:51 horas: As ruim já foi
- Dia 14 de maio, imagem 17:
- Werner - 16:51 horas: Aí passa 3; 2 boa 1 ruim
- Renan - 16:51 horas: Não gay; Essas 10 tá vendida; Sério; Não dá pra fazer troca

- Werner - 16:52 horas: Mais nego não vai saber Gi; Fi
- Renan - 16:52 horas: Vai sim
- Werner - 16:52 horas: Vc nem sabe a cor que é; Larga mão de ser burro; Sabem nad
- Renan - 16:52 horas: Os cara conhece; Nem mexe manda; Mano
- Dia 14 de maio, imagem 18:
- Werner - 16:52 horas: Blz
- Renan - 16:52 horas: As 10 das boa tá vendida; Sério; Posso me queima não; Os cara pagou caro; Luca que se foda
- Werner - 16:52 horas: Quanto vc vendeu ? (comentando a mensagem anterior de Renan: "Os cara pagou caro"); 3 por 10; Então põe uma ruim (comentando a mensagem anterior de Renan "Luca que se foda")
- Werner - 16:53 horas: No rabo dele

Nota: Werner insistiu em trocar "balas" boas por ruins com Renan, que nega, informando que já estão vendidas e alegando que não pode se "queimar" (ficar com má fama).

(fls. 148/150)

- Dia 14 de maio, imagem 19:
- Renan - 16:53 horas: 40 cada (respondendo a mensagem anterior de Werner: "Quanto vc vendeu"); Só 5 foi pro Mateus de Marília; As outras cinco fico com duas e vendi 3 pro couto; As ruim já foi tudo; Kkk;
- Renan - 16:57 horas: Você já usou todas as suas??; Kkk;
- Renan - 16:58 horas: Fica dando bala atoa pra essas minas não mano
- Werner - 17:02 horas: Nem comecei ainda kkk; Viemos maquinando; Maquinado
- Dia 14 de maio, imagem 20:
- Renan - 17:03 horas: Kkkkkkk; Minha nossa; Tem lolo aí ?
- Renan - 17:04 horas: Alguma notícia da loira do tráfico?; Kkk
- Werner - 17:04 horas: Por hr nada (respondendo a mensagem de Renan: "Alguma notícia da loira do tráfico?"); Não sabemos se está guardada; Ou já está aí nas ruas de Maringá; Acabou a mamata - Werner - 17:05 horas: 3 gringas por 100; Para turma de Maringá
- Dia 14 de maio, imagem 21:
- Renan - 17:05 horas: Kkk; Fudeo
- Renan - 17:06 horas: Vc tá com gringa aí fla nisso; Se tiver quero metade lá; Nem vou bebe mano; Só água msm
- Werner - 17:13 horas: Tenho nada

Nota: "Gringa" é uma nomenclatura utilizada para denominar droga sintética, êxtase.

- Dia 14 de maio, imagem 21:
- Werner - 18:05 horas: Jonas; Viado; Quer bala; kkk
- Renan - 18:07 horas: Manda se fude
- Dia 14 de maio, imagem 22:
- Renan - 23:44 horas: Vê com a menina pra Entra com As paradas

Nota: Werner informou que "Jonas" pediu "bala". Renan fala para Werner ver com a menina para entrar com as "paradas" (supostamente com a droga na festa que ocorreu nesta cidade, para onde Werner iria, quando foi surpreendido por esta Polícia com a droga sintética).

Assim, repita-se, sintomaticamente, não há como negar a imputação de tráfico. A intenção do tráfico ilícito de drogas restou devidamente configurada, em razão da quantidade de droga apreendida e das provas obtidas na investigação, em especial do conteúdo extraído das trocas de mensagens existente no aparelho celular do réu. Consigna-se, ainda, ser irrelevante para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja surpreendido efetivamente comercializando as substâncias ilícitas, tendo o legislador feito expressa menção ao simples ato de o indivíduo "trazer consigo" a droga, desde que haja a finalidade de comercializá-la a terceiros, o que restou demonstrado nos autos, ficando evidente que a droga era destinada a venda para consumo de terceiros.

Resta a análise da incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. In verbis:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto

a dois terços, se:

I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância;

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; (destaquei)

A esse respeito ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA: "a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública" (Legislação Criminal Especial Comentada. Volume Único. 4ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 973).

Destaca-se que o Tribunal de Justiça firmou o entendimento que: "para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância" (HC 407.487/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017). Embora o réu não tenha sido flagrado no local do evento, foi surpreendido a caminho, em chácara próxima, local em que diversas pessoas se encontraram para os preparativos da festa ("Black"), e também retornariam, utilizando como extensão do evento festivo.

Acrescenta-se ainda que a intenção da traficância na festa "Black" restou devidamente demonstrada pelas transcrições das conversas, inclusive a forma que entrariam com os comprimidos de "ecstasy" no recinto ("Vê com a menina pra Entra com As paradas").

Oportuno consignar que também se extrai dos diálogos que o fornecimento da droga também acontecia de forma gratuita, especialmente para garotas, configurando do mesmo modo o tráfico nessa hipótese.

Por conseguinte, provada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, a procedência do pedido condenatório é de rigor.

Delineada a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, resta fixar a reprimenda devida.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu não ostenta antecedentes criminais, fls. 38/40, como também é primário. Porém, de outro lado, tem-se significativa gravidade de sua conduta. Anote-se que ao contrário do que se vê como regra, tinha o agente ótima condição social e econômica, como ressaltado por ilustres testemunhas arroladas pela Defesa. Aproveitando-se desta condição e imagem, como se verifica das comunicações que constam do relatório de fls. 140/163, realizava intensa atividade de tráfico, comunicando-se com pessoas de várias regiões.

Isso sem contar que não apresenta qualquer freio moral ao se utilizar dos entorpecentes, de natureza "refinada" por assim dizer, em festas que frequentavam pessoas de alto poder econômico, não só com o objetivo de angariar recursos como para a obtenção favorecimento sexual, o que denota sua degradação, fls. 160: "- Werner - 23:39 horas: Rapaz; O DUM conhece essas MuiE; Kkk; Deve dar droga pra elas; figurinhas indicando risada do aplicativo - Dandola - 23:39 horas: Vamos dar Tbm - Dandola - 23:40 horas: Cume tudo - Werner - 23:40 horas: Sim kkk (respondendo a mensagem de Dandola: "Vamos dar Tbm")"

Anote-se, aliás, que o réu em seu interrogatório não apresenta, mesmo diante destas gravações, qualquer conduta digna, eis que sem qualquer reboço, nega o evidente. Por outras palavras, não se trata de qualquer hipossuficiente, mas sim, de pessoa com nível sócio econômico prestigiado, que se dedica ao tráfico de forma

despropositada, o que realça seu dolo.

Logo, a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, montante adequado em primeira fase a tutelar a conduta.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, embora o réu seja primário e não ostente antecedentes criminais, não incide no presente caso a causa de diminuição de pena do art. 33 da Lei 11/343/06, isso porque demonstrado o envolvimento na comercialização de drogas de forma perene, ou seja, descartada a situação ocasional da conduta, móvel do benefício.

Afinal, não é simples fora de estruturas criminosas, a aquisição destes entorpecentes "especiais", destinados a jovens que frequentam festas de elevado poderio econômico.

De outro lado, presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. Portanto, majoro a pena em 1/3 (um terço), restando fixada em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), bem como a natureza grave do crime e suas consequências sociais, o regime de início do cumprimento da pena será o regime fechado.

Em decorrência da pena aplicada é impossível conceder ao réu os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, anote-se que apreendido aparelho, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15).

O art. 243, parágrafo único da Constituição Federal preconiza o perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, veja-se: "Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei." (grifei)

Há de se ressaltar que a Lei Antitóxicos impõe a inversão do ônus da prova ao réu, de modo que a ele, acusado de narcotráfico, compete demonstrar cabalmente a origem lícita do seu patrimônio.

Nesse sentido, estabelece o art. 60, nos seus §§1º e 2º, da Lei 11.343/2006, que: "Art. 60, §1º - Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultará ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produção de provas acerca origem lícita do produto, bem ou valor objeto da decisão. §2º - Provada a origem lícita do produto, bem ou valor, o juiz decidirá pela sua liberação."

Ao comentar o §2º do referido artigo, assinala o renomado Prof. VICENTE GRECO FILHO: "Outra particularidade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no §2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes." (Lei de Drogas Anotada, Ed. Saraiva, 2007, pág. 189).

É de rigor, portanto, o perdimento do objeto utilizado no tráfico de drogas, ou seja, o aparelho celular apreendido, eis que é instrumento essencial à aquisição, negociação e distribuição dos entorpecentes, conforme demonstrado.

Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para condenar WERNER FAGUNDES, como incurso no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena 12 (doze) anos de reclusão, em REGIME FECHADO, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário fixado no mínimo legal da Lei de Drogas.

Estando o réu em liberdade, eis que concedida pela E. Superior Instância, conforme Habeas Corpus concedido (fls. 71/75), poderá recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Decreto, ainda, o perdimento do bem (celular) apreendido em decorrência da traficância, na forma acima fundamentada. Autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA